

1500546-29.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... a própria afirmação do acusado de que praticava o tráfico justamente naquele local.

Irrelevante, ainda, para a caracterização do tráfico, a ausência de efetiva mercancia, por ocasião da abordagem.

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500546-29.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500546-29.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2128680/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA

PLANTÃO, 24911544 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2128680 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA, 58/2022 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAWÃ KAIK DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

KAWÃ KAIK DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11.05.2022, por volta das 15h37min, na Rua Isaltino Aires Ferreira, 11, Recanto Elizabeth, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista - SP, trazia consigo, para venda ou entrega de qualquer forma a consumo, 06 porções de cocaína, pesando 10g e 70 porções de crack. pesando 20g,

substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls.99/100). Em seguida a denúncia foi recebida.

Ante a juntada do laudo do local dos fatos, o Ministério Público aditou a denúncia (fls.87), para incluir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei.11.343/06, e que foi recebido.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ato contínuo, o acusado foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal e a conseqüente condenação do réu, entendendo presentes prova da autoria e materialidade delitiva.

Por sua vez, a Defesa requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da prova produzida pela guarda municipal. Requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da fragilidade da prova produzida. Por fim, teceu considerações acerca da pena, regime de cumprimento, pedido para afastamento do privilégio e da causa de aumento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da prova produzida pela guarda municipal.

Consoante adiante se verá, em patrulhamento de rotina, por local conhecido como ponto de venda de drogas, os guardas avistaram o acusado, não apenas no período da manhã, mas, ainda, no período da tarde (momento do crime), ocasião em que estava na companhia de outro rapaz, tendo ambos dali se afastado, em sentidos opostos, logo da aproximação da guarda. Neste momento, enquanto o rapaz que acompanhava o acusado conseguiu sair em fuga, o acusado teria dispensado uma sacola contendo drogas, sendo ele detido em flagrante.

Ou seja, não apenas estava o acusado em local conhecido como ponto de venda de drogas como, de fato, dali tentou se afastar, ante a aproximação da guarda, situação que levantava, sim, grande suspeita de algo ilícito, fato confirmado, logo após, por ocasião da dispensa da sacola contendo drogas. Ou seja, a situação justificava a pronta atuação da guarda, assim como justificaria, inclusive, a atuação de qualquer pessoa do povo, ante a situação de flagrância.

A respeito, aliás, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os guardas municipais estão "legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301, do Código de Processo Penal". E "se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime" (RHC nº 7.916, rel. Min. Fernando Gonçalves).

Neste contexto, também há legalidade na prisão em flagrante efetuada por guarda municipal: STJ, HC nº 129.932, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. No mesmo sentido, "não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante e, conseqüentemente, em prova ilícita, porque efetuada por guardas municipais, que estavam de ronda e foram informados da ocorrência da prática do tráfico de drogas na ocasião, se pode fazê-lo qualquer do povo" (RHC nº 20.714, rel. Min. Hamilton Carvalhido).

Ademais, não obstante as arguições da Defesa, a situação ora em análise não se assemelha àquela colocada em discussão, por ocasião da decisão de uma das Turmas do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp 1.977.119. O que se decidiu, naquele caso específico, foi a limitação da atuação da guarda municipal em diligências investigativas, inerentes à atuação da polícia.

No caso, em tela, no entanto, diante da situação flagrancial, não se poderia exigir que os guardas simplesmente acionassem a polícia para que, apenas então, fosse efetuada a abordagem do acusado e apenas depois se verificasse o material dispensado por ele.

Dessa forma, repita-se, não há evidência de qualquer ilegalidade na ação da guarda civil, com a ressalva de que os agentes apenas atuaram para a manutenção da ordem

pública.

No mérito propriamente dito, de rigor a procedência do pedido contido na denúncia.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.04/09), auto de exibição e apreensão (fls.10), laudo de constatação (fls.11), exame químico toxicológico (fls.70/770, laudo do local dos fatos (fls.82/84) e depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também é certa.

Ouvido em juízo, o acusado alegou ser traficante, mas negou a propriedade da droga apreendida naquela oportunidade. Disse que havia outro rapaz em sua companhia, sendo deste o entorpecente encontrado pela guarda municipal. Disse que era conhecido do local, pois ali permanecia. Residia em outro bairro e, quando sua filha precisava de fraldas ou alimento, geralmente subia no local da abordagem para a prática do tráfico. Isto ocorria de vez em quando, pois apenas quando precisava de dinheiro. Acrescentou, inclusive, que tinha subido até o local, naquele dia, justamente para pegar droga para vender, embora não o tivesse feito, ainda. Ou seja, embora tenha admitido ser traficante, o fato é que ele negou a propriedade da droga indicada na denúncia.

No entanto, sua versão deve ser afastada, pois o conjunto probatório produzido em audiência o incrimina.

Diferentemente do que entendeu a Defesa, e do que foi alegado pelo acusado, a prova dos autos é coesa e harmônica no sentido de que o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, a droga mencionada na denúncia.

O guarda municipal Benedito disse que passou pelo local e notou que ele ali estava, no período da manhã. No mesmo dia, mas no período da tarde, o depoente novamente avistou o acusado no local, mas agora na companhia de um segundo rapaz. Notou quando os rapazes tentaram se afastar do local, seguindo cada um para um lado, ante a aproximação do depoente. Viu, então, quando o acusado dispensou uma sacola contendo drogas. O entorpecente foi encontrado há 10m do local da abordagem. O outro rapaz, por sua vez, não foi detido.

O Guarda Municipal Alessandro corroborou, na íntegra, a versão de seu colega de trabalho e, tal como Benedito, contou que não conhecia o acusado antes do ocorrido. Em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, nas proximidades de uma escola, avistou o acusado pela manhã. Logo à tarde, reparou que o acusado ainda estava no local, agora acompanhado de outro rapaz. Este segundo elemento saiu correndo, ao notar a presença da guarda. O depoente seguiu na direção do acusado, que saiu na direção oposta à tomada pelo outro rapaz. No trajeto, o depoente viu quando o acusado dispensou a droga. O entorpecente estava embalado individualmente. Em poder do acusado havia dinheiro. Questionado a respeito, o acusado negou que a droga fosse de sua propriedade.

Pois bem. Os relatos dos guardas são uníssomos no tocante à dispensa da droga pelo acusado. Eles não titubearam ao afirmar terem visto o momento da dispensa e pelo acusado. Ou seja, eles afastaram a alegação do acusado e de que a droga pertenceria àquele indivíduo que saiu em fuga e não foi detido pela guarda.

Motivos não existem para duvidar do relato dos guardas.

Nada indicar que eles teriam incriminado, injustamente, a pessoa do acusado.

Não se pode simplesmente ignorar o relato daqueles a quem o Estado conferiu o dever de velar pela segurança e ordem pública, ainda mais quando indícios não existem para tal providência.

Também não era de se exigir da guarda municipal que arrolasse pessoas alheias aos guardas. Ora, justamente por se tratar de delito de tráfico de drogas, crime que envolve represálias, praticamente inviável que civis sejam arrolados e venham em juízo testemunhar, pois é sabido sobre o grande temor que existe em depor contra traficantes.

Da mesma forma, no caso em questão, chama a atenção a própria narrativa do acusado acerca do que fazia no local, em que pese a negativa da propriedade da droga. Ora, ele mesmo admitiu ser traficante, justamente naquele local, e ainda acrescentou que ali estava com o fim de adquirir droga para venda.

O fato é que sua versão apenas corrobora a certeza da traficância e da propriedade

da droga que, repita-se, foi constatada pelos guardas. Mesmo porque, como ambos os guardas ressaltaram em juízo, o acusado ali estava desde o período da manhã. E mais. Em seu poder houve o encontro de R\$ 269,00, fatalmente produto da venda já realizava, conclusão a que se chega ante a própria afirmação do acusado de que praticava o tráfico justamente naquele local.

Irrelevante, ainda, para a caracterização do tráfico, a ausência de efetiva mercancia, por ocasião da abordagem.

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstância que cercam o agente envolvido" (RT 729/542), "Em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para uso próprio; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed. RT.2004, item 5, pag.96)_

Também devidamente demonstrada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que o tráfico praticado pelo acusado ocorria nas imediações de escola. Neste sentido há o laudo pericial do local dos fatos, além da versão dos próprios guardas ouvidos.

E acerca da aplicação da referida causa de aumento de pena, forçoso mencionar que o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, já se manifestou exaustivamente a respeito e no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visa a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento.

Na espécie em exame, os fatos se deram nas proximidades de escola, em pleno dia da semana e horário nos quais provavelmente a escola estava em funcionamento. É o suficiente para atestar que maior era a chance de disseminação de droga em área de maior aglomeração de pessoas.

No mais, diante da certeza da materialidade e da autoria delitivas, passo a dosar a pena a ser imposta.

Partindo-se do mínimo legal de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, não vislumbro a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis e que exijam a fixação da pena acima do mínimo legal. Em que pese a variedade de droga apreendida em poder do acusado, a quantidade não extrapola o normal para a espécie (10g de crack e 20g de cocaína) e não pode, como única condição, justificar o aumento, se confrontada com as outras circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Na segunda fase de aplicação de pena inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas e que alterem o quantum fixado.

Na terceira fase de aplicação de pena verifico a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, razão pela qual, aumento a pena em 1/6 e chego a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, pelo crime de tráfico.

Ainda nesta fase, deixo de reconhecer o tráfico privilegiado no caso em comento.

Ora, a referida causa de diminuição de pena tem sua razão de ser para o chamado "traficante de primeira viagem", condição atribuída àquele que possui "estoque" diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o próprio vício.

A respeito, a doutrina e a jurisprudência apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

No caso em tela, o acusado levava consigo a quantia de R\$ 269,00, fatalmente produto da mercancia já realizada naquela data, além de 70 porções de crack e 6 porções de cocaína. Mas não é só. O acusado ostenta passagens na vara da infância e juventude (cf. Fls.32), tendo, ainda, admitido que incorria no tráfico "de vez em

quando" para complementar a renda familiar.

Nesse sentido, tem decidido o C. STJ: "Esta Corte é uníssona no sentido de que atos infracionais anteriores não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a penabase, tampouco para induzir a reincidência, entretanto, tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas. Precedentes. 4. Desde que devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados

Mas não é só. Ele ainda foi detido em flagrante delito e respondeu pelo trafico em discussão, após ter sido colocado em liberdade em razão de sua prisão em flagrante por delito anterior.

Já elementos que indicam, pois, que ele não era traficante de primeira viagem e, ainda, que ele era dado a atividades criminosas.

Como se vê, tais circunstâncias denotam a especial culpabilidade do acusado, sendo incompatíveis com a figura do traficante ocasional, sujeito ativo a quem a lei objetiva emprestar tratamento diferenciado, razão pela qual inaplicável a redução. Reiterativa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a incidência da referida minorante - caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa. (Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a aplicação da causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV - No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas - 140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack) justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas', inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...) " (5ª Turma, HC nº 303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015) .

Diante do quantum de pena, inviáveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

No tocante ao regime inicial de pena, atenta às circunstâncias favoráveis do artigo 59, do Código Penal, bem como atenta ao quantum de pena, primariedade, fixo o regime inicial semiaberto.

"Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59, do CP, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime" (STF HC indeferido. HC 76.191-1, 1ª T, 10.3.98, DJU de 3.4.98).

Não poderá o réu apelar em liberdade, tendo em vista que seguem presentes os pressupostos da prisão cautelar, robustecidos por esta decisão, além da natureza do delito cometido, e de ter o réu respondido a este processo preso. .

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o acusado KAWA KAIK DE OLIVEIRA ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, fixados estes no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral..

Declaro, em favor da União (FUNAD), o perdimento do valor apreendido nos autos, o que faço forte no art. 63 e seu § 1.º, da Lei n.º 11.343/2006. Expeça-se o necessário

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 08 de setembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

-Juíza de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA